EL POR QUÉ Y PARA QUÉ DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Óscar Eduardo González Camacho

I.- VALORACIONES PREVIAS

El control del poder resulta imprescindible, no sólo para la conservación del Estado de Derecho, sino para el fortalecimiento del sistema democrático. Sin justicia no hay paz social, y sin paz social sobreviene el caos y la opresión. Desde esta perspectiva (y desde cualquier otra), es vital un adecuado aparato jurisdiccional que, como control externo, se encargue de velar por el respeto a la juridicidad, y, ante todo, por la protección plena de los derechos o intereses de la persona. En este sentido, la Constitución impone unos mandatos específicos y claros, que pretenden garantizar al ciudadano esa protección adecuada, concediendo un especial énfasis en aquellas lesiones ocasionadas por la actuación del Poder Público.

En efecto, la Administración siempre ha encontrado portillos por los cuales huir de la adecuada fiscalización judicial, que, sin ser absoluta, sí debe ser plena en el ámbito jurídico. No se pretende en modo alguno imponer un gobierno de jueces, ni colocarlos en posición de administradores directos, sino tan sólo de hacer efectivo el control universal de la conducta administrativa, con protección plena de los derechos e intereses que a toda persona garantiza la Constitución (Tutela Judicial Efectiva).

Teniendo lo anterior como premisa, se produjo hace algunos años un cambio de paradigma, y con ello, una modificación sustancial del proceso contencioso administrativo, con el que se procuró brindar una respuesta fluida a toda lesión que sufra el ciudadano ante la "conducta pública", con garantía adicional del cumplimiento exacto de la legalidad. A ello fue permeable el legislador, el que, atendiendo el clamor doctrinal y la línea jurisprudencial ya no tan recientes, introdujo en los textos normativos un control pleno de las conductas públicas, en plena concordancia con la protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona. La reforma brindó, además, instrumentos procesales que, sin ser

perfectos, han dado los insumos básicos a los Juzgadores para que ejerzan una verdadera y efectiva protección de la persona en equilibrio con la protección del interés público.

Es esto último lo que cabalmente debe tener presente quien se ocupa de la actividad jurisdiccional en esta materia, convirtiendo ese principio en el norte de todo su quehacer como judicador (a), sea: la protección de la persona frente a la arbitrariedad de la Administración (lamentablemente frecuente). Y a ello obedecen mis siguientes palabras como un reiterado recordatorio y, si se quiere, como una súplica en grito silencioso, pues muy a mi pesar (y el de muchos) lo anterior no se cumple y, por el contrario, está ausente en una cantidad considerable de asuntos que en la actualidad se resuelven en nuestra amada jurisdicción.

Bien es verdad, y es necesario y propio reconocerlo, que en este fenómeno existen también factores externos y ajenos a quienes resuelven judicialmente el conflicto planteado. Las deficiencias procesales y probatorios de carácter insalvable de quienes litigan en la materia. La excesiva (abrumadora) carga de trabajo que agobia uno y otro día a los jueces y las juezas, son factores que juegan de manera muy negativa en contra de la buena Administración de Justicia. A eso hay que agregar (y hay que decirlo con todas las palabras, así sea políticamente incorrecto) que existe un ambiente laboral institucional enrarecido y tenso, que termina afectando, de manera seria, el resultado o producto final de quien resuelve en una u otra etapa.

Empero, me limitaré a lo que aquí corresponde, a los factores intrínsecos del ámbito jurisdiccional, que son (y si acaso) los que me competen, sin demeritar ni desconocer (como recién lo he dicho) los elementos exógenos al juez (a).

Para decirlo en forma directa y asertiva, considero que son varios componentes de orden jurisdiccional los que están influyendo en la asombrosa cantidad de resoluciones adversas a los administrados en la actual composición funcionarial del contencioso. Se trata de un proceder ya sistemático (resentido por muchos y en crecimiento), en el que la Administración obtiene el triunfo en la abrumadora mayoría de los procesos, dejando un porcentaje pírrico para la victoria de los administrados. Creo que para ello confluyen varios elementos. En primer término, se presenta una débil o deficiente capacitación en materia de derecho público y en particular de derecho administrativo y constitucional. Al respecto existen una cantidad muy considerable de resoluciones que producen verdadera perplejidad

en temas básicos que se creían superados. En segundo lugar, han asumido la judicatura personas con muy poca o ninguna experiencia en la materia. En tercer lugar, se presenta una preocupante permeabilidad (cuando no sumisión) de algunas personas judicadoras a factores exógenos a su criterio jurídico personal, que inciden en forma determinante como mecanismo de presión. Así, a modo de ejemplo, tenemos a la prensa que prejuzga o crea opinión colectiva en múltiples ocasiones desapegada a la verdad; las redes sociales, las opiniones políticas, o bien, el criterio de los superiores (oficial o no) en temas concretos pendientes por resolver. La persona judicante que, en nuestra materia, no es capaz de enfrentarse, resistir y mantener su opinión parcial e independiente contra tales factores, no puede, no debe, ocupar ni ejercer la inmaculada tarea de impartir justicia.

La independencia y fortaleza de criterio de un verdadero Juez, es determinante cuando se trata de la protección de los derechos e intereses de las personas, máxime cuando se trata de situaciones jurídico-públicas.

Pero entre ellos, el más desconcertante (como si los demás no lo fueran), es el conservadurismo ideológico que se ha hecho presente en algunos de los integrantes actuales de la jurisdicción. Y por "conservadurismo" hago referencia a una posición *pro-Administración Pública*, en vez de la protección al ciudadano. Respetable ciertamente, pero sin duda alguna, dañina y lacerante para el servicio público de la justicia. Aquí me atrevo a afirmar con absoluta contundencia, que respeto el conservadurismo inteligente y fundado, pero repruebo y combato el que se erige sobre la ignorancia y el temor. Lamentablemente es el segundo grupo el que nos atormenta por doquier.

Con ello no afirmo, ni mucho menos (no quisiera que se caiga en semejante confusión), que toda demanda o medida cautelar deba declararse con lugar. No lo creo así, ni lo hice así en toda mi vida jurisdiccional. Pero otra cosa muy distinta es, que se abracen una y otra y otra vez, criterios conservadores en pro de la Administración, allí donde hay evidencia de lo contrario, o al menos duda, que debería beneficiar al administrado. Esta última fue la visión de nuestra Sala Constitucional originaria, y de quienes, como equipo fuimos encargados de la redacción e implementación del Código Procesal Contencioso Administrativo, a saber: una clara visión y protección del administrado.

Frente a esta crisis en la calidad y dirección de los pronunciamientos del contencioso administrativo, he llegado a pensar incluso, en la innecesaria representación jurídico

profesional de la Administración Pública en tribunales, pues pareciera que, en algunos casos, el poder público ya está bien y suficientemente representado dentro del propio órgano jurisdiccional encargado de resolver. Al parecer, algunos de nuestros jueces se equivocaron de profesión, pues nacieron no para la judicatura, sino para ser procuradores del Estado.

Los señores jueces y las señoras juezas han de tener presente que si ya resulta repulsiva y frustrante la arbitrariedad y el irrespeto al Estado de Derecho que cotidianamente realiza la Administración Pública en ejercicio de sus potestades de imperio; tanto más resulta la actuación o la indolencia del órgano jurisdiccional, cuando deniega injusta e ilegalmente lo que corresponde a quien pide protección.

Ya de por sí sabemos que el ser humano y la Administración que a ellos representa, desatiende cotidianamente el ordenamiento jurídico, y eso es grave[1]. Pero lo dramático viene, cuando los jueces (as) encargados de frenar el abuso, la antijuridicidad y la arbitrariedad de aquella, para proteger a la persona lesionada, no realizan su labor de manera equilibrada, incisiva, valiente, objetiva, eficaz y eficiente, dejando de lado la sensibilidad debida para quien es destinatario del mandato y el quehacer público. Sin tal tutela, todo está perdido. Pulverizamos entonces el Estado de Derecho; el poder abusivo no encuentra freno, las lesiones no reciben reparo, y el sistema como tal se hunde sin remedio, dando paso: al totalitarismo, a la justicia por propia mano, a la resignación y el silencio de la víctima frente a la lesión sufrida, y cuando menos, a la desconfianza y la frustración frente al aparato jurisdiccional disfuncional y, por cierto, caro para todos.

Los justiciables pretenden del juez-jurista, que busque en la exégesis de la norma su recta aplicación en procura de la justicia, de lo razonable y de lo que el interés público demanda[2], pues hay de quien se justifica en la letra de la ley para realizar o aprobar lo injusto. Y si aún después de realizar aquel ejercicio, no le es permitida una interpretación recta y correcta, habrá de luchar, con todas las energías, por la abrogación o anulación de lo que en pernicioso se ha convertido. La ley injusta no debe ser ley.

---

[1] Otórgale a un ser humano la más minúscula atribución (poder), y generalmente le verás ejercerla (o) con todo rigor, y las más de las veces, con prepotencia, exceso y altivez. Tristemente debemos reconocer que, se trata de una condición de origen en nuestra especie actual.

[2] Es necesario entender que existe un marcado interés del colectivo en una adecuada tutela jurídica de todos sus miembros, lo que implica afirmar que la efectiva protección de la persona en el ámbito judicial es un componente intrínseco y esencial del interés público. De allí que, sin aquella protección se lesiona gravemente el interés público.

Los y las juzgadoras han de tener la agudeza de la renovación del ordenamiento y de la jurisprudencia, de acuerdo con los cambios que la realidad impone, sin esperar, necesariamente, a que una reforma legal se los permita. El Juez sí crea Derecho, lo contrario es una quimera teórica sin ningún respaldo en la realidad.

En este sentido, cuidado con los dogmas infranqueables o la jurisprudencia vetusta pacíficamente admitida y que sirve de camino al juez perezoso. ¡Cuánta valía y virtud en la sabia escritura del libro empolvado y añejado en la madurez de las ideas; más cuanta desgracia en la petrificación de estas y en su irreflexiva obediencia, pues limitarán la imaginación y el don maravilloso del cambio favorable!

Por ello repruebo con energía al Juzgador (a) que se encierra en los rígidos aspectos procedimentales para esquivar el conocimiento justo del fondo. Es claro que decir no, o bien anular, es más sencillo que el sí con fundamento, trabajo, esfuerzo e ingenio mental. De allí que, en no pocos casos se opta por rechazar insensiblemente lo pedido y deshacerse de un expediente más que contará como número en la estadística. El proceso no puede ser un obstáculo para otorgar la razón a quien la tiene.

Solo es Juez (a), el que procura determinar a quién corresponde el derecho dentro de la espesura del conflicto, y después, encuentra el modo o mecanismo pertinente para otorgarlo.

Llegados a este punto, se hace imperativo señalar la necesaria e irrenunciable formación del **Juez (a) cautelar.** Se trata de un funcionario que requiere de unos amplios conocimientos de derecho; de una adecuada comprensión y visión de la finalidad del proceso contencioso (que no es otro que la protección del ser humano y su entorno general); propenso a la protección de la persona; con valentía para tomar las decisiones necesarios por encima de las presiones; que resguarde su independencia de criterio contra viento y marea; con la sagacidad para crear y disponer más allá de lo tradicional; con la minuciosidad necesaria para entender la situación fáctica que se le presenta, protegido contra los prejuicios, pero ante todo, con la sensibilidad de ser humano, que le permita comprender la necesidad (cuando no la tragedia) de quien desde la puerta del edificio judicial, clama por protección inmediata, sofocado por la arbitrariedad pública y la grave lesión inminente que impacta o impactará su vida, la más de las veces de manera irreversible.

Un **NUNCA, UNA PROTESTA, LA EXIGIDA DIMISIÓN,** para el Juzgador (a) tozudo; insensible; tradicional y conservador; que mira al justiciable con el prejuicio imperdonable de "pillo" o como un número más; que sin el mínimo detenimiento altera o no comprende los hechos urgentes que se le exponen; o que se encubre en la excusa formal del "por qué no vino antes" para denegar la justicia provisional (y ante todo provisionalísima), sin la cual la tutela judicial efectiva se desecha y queda diluida en un proceso que navega en el transcurso de los años. ¿Para qué la razón y un derecho otorgado en sentencia de fondo y dolorosamente ejecutada, si se recibe en la ancianidad lo que me fue despojado o negado en la juventud? ¿para qué una ilegalidad dispuesta en sentencia si ha de ser ejecutada por los nietos del victorioso fallecido? Si la tutela cautelar (y sobre todo la inmediata) no funciona frente a la dilación grotesca de nuestro proceso de fondo, todo, absolutamente todo, pierde sentido. Si esto ocurre, como está ocurriendo hoy, dejemos de mencionar siquiera la tutela judicial efectiva como derecho fundamental, pues representa no solo una quimera, sino una burla de frente para el administrado.

Lo más frustrante, lo más doloroso de todo ello, es comprobar, día con día, cómo algunos de los jueces y las juezas actuales, desatienden, desoyen estos inviolables principios, y con desdén miran impávidos hacia un lado, **justificándose a sí mismos** con aspectos formales, criterios temporales o peligros imaginarios para el bien o interés público. Y más aún: sin ninguna intención de cambio ni introspección sincera, y, por el contrario, furiosos contra quienes razonablemente critican su inexpugnable ejercicio de **poder** jurisdiccional. Es imposible expresar con palabras la frustrante impotencia que con ello se siente una, y otra, y otra vez.

Si el poder encargado de controlar la arbitrariedad cae en los mismos vicios de quien controla; si por ignorancia, temor, protección de sí mismo, prepotencia o conservadurismo, deja de funcionar adecuadamente; no existirá posibilidad alguna de salvar el derecho de los que, mancillados por el opresor, claman por justicia; y en ese caso, el sistema democrático de derecho, están, irremediablemente, condenados a morir.

Dicho lo anterior, se hace imprescindible recordar una vez más, los fundamentos y finalidad misma de esta materia jurisdiccional, que parecen haber quedado en el olvido de algunos con el reciente ejercicio de la actividad jurisdiccional.

II. El Poder Judicial y el Control Pleno de la Administración Pública en el marco de la Separación de Poderes.

Nuestro Constituyente reafirmó entre otras muchas cosas, la distribución orgánica y funcional de Montesquieu, así como la preservación de la libertad y el juego de contrapesos, todo dentro de un marco de flexibilidad[3]. Recoge el principio de manera explícita en el artículo 9, y aparece con el sentido funcional y flexible que hoy debe ser entendido, en el Título IX del Poder Legislativo (arts. 105 y siguientes), cuando habla de la "potestad legislativa"; en el Título X que trata del Poder Ejecutivo (art.130 y siguientes), en el que se refiere a la " función ejecutiva y potestad reglamentaria" y en el Título XI que trata del Poder Judicial (arts. 152 y siguientes), en el que alude a la potestad jurisdiccional, para la que establece independencia y sometimiento único a la ley[4].

La independencia del Poder Judicial, opera en una doble vertiente: primero, impidiendo que ningún otro Poder interfiera en su función de "administrar justicia", en la que el Juez sólo está sometido al ordenamiento jurídico, y segundo, en cuanto otorga el monopolio y la unidad de jurisdicción al Poder Judicial. Así, bajo este segundo aspecto, la jurisdicción es exclusiva del Juez, lo que excluye la atribución de competencias judiciales al Poder Ejecutivo o a las comisiones parlamentarias, así como cualquier injerencia en el régimen normal por parte de jurisdicciones especiales, que supongan directa o indirectamente una intervención del Ejecutivo o el Legislativo[5].

Pero además de los clásicos, se insertan nuevos órganos a nivel constitucional, como es el caso del Tribunal Supremo de Elecciones; de la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, etc, etc., que, aun no siendo Poderes, rompen en principio con la trilogía

---

[3] Con ello no se afirma, claro está, que la Constitución sea el simple resultado de la teoría del Barón de la Brède. Ello sería irrisorio, pues es mucho más que eso, ya que se trata del resultado de un pensamiento y construcción que cubre casi la totalidad de la historia humana.

[4] Al respecto puede verse MOVILLA ÁLVAREZ (Claudio): *Sistema Político y Jurisdicción Contencioso Administrativa*, en la obra conjunta coordinada por LÓPEZ PINA (Antonio): División de Poderes e Interpretación (Hacia una Teoría de la Praxis Constitucional). Editorial Tecnos. Madrid. España. Primera Edición. 1987. Pag. 103.

[5] Sobre este aspecto puede verse PECES BARBA (Gregorio): Derechos Fundamentales. Madrid. España. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. Tercera Edición. 1980. Pag. 188 y ss.

clásica de poderes, pero no con la concepción abstracta de la doctrina en análisis. Muy por el contrario, la confirma, pues mantiene en su línea lo que algún autor denominaba como la "distribución de potestades". Y ello por varias razones: primero, porque se dirigen, entre otras cosas, a garantizar la libertad política y la moderación pregonada por el autor francés; en segundo lugar, porque con ellos se reafirma y fortalece el juego de pesos y contrapesos; tercero, porque se confirma la interdependencia funcional que entre ellos debe imperar, y por último, porque de un modo u otro, tales órganos (que aunque constitucionales son tan sólo órganos) normalmente reputan su quehacer en una de las funciones clásicas a las que se ha venido aludiendo, aunque orgánicamente no pertenezcan a ellos en forma directa. Estos no son más que reflejo del crecimiento estatal y de su ampliación de funciones (en las que por ejemplo ha habido un gran desarrollo en las de fomento y las prestacionales), que exigen nuevas modalidades de control a fin de preservar el nuevo modelo implantado de Estado de Derecho democrático y social.

Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante nuevos órganos constitucionales, que, por no estar dirigidos estrictamente al control, sí obligan a una adaptación funcional y organizativa en la división y ejercicio del Poder[6], con lo cual se altera la trinidad dogmática de la división[7]. Hay ahora, una nueva distribución horizontal y vertical. Es este el caso de la Sala Constitucional y de la propia Administración Pública, que, con su crecimiento desmedido y sus innegables potestades, han superado la mera acción ejecutiva, para convertirse en agentes normativos, e incluso prestacionales, como parte de las exigencias de

[6] Como señala RODRÍGUEZ OLIVER, en este momento histórico la organización de poderes es mucho más compleja, por lo que no puede realizarse exclusivamente sobre la existencia de tres poderes distintos, encerrados cada uno en sí mismo, y autosuficientes y aislados frente a los demás. RODRÍGUEZ OLIVER (José María): "*El Artículo 24.1º de la Constitución y la Ampliación de la Competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa".* En el libro conjunto titulado El Poder Judicial. Vol. III. Dirección General de lo Contencioso del Estado. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. España. Primera Edición. 1983, pag., 2439"

[7] En esto son clarificadoras las palabras de TORRES BOURSAULT cuando sostiene que " ... la trinidad de poderes se ha hecho demasiado simple para explicar la división del poder en un Estado y en una sociedad acentuadamente compleja, sin que ello quiera decir que su funcionalidad jurídico-política carezca de sentido, sino que simplemente ésta se ha modificado, en la medida en que todavía tiene la función de asegurar la unidad y la estabilidad del Estado democrático, de contribuir a su racionalidad, introduciendo factores de diferenciación y articulación en el ejercicio de poder, lo que unido a la acción de crítica y control de la oposición en el seno del Parlamento, pone límites y contrapesos a su ejercicio arbitrario por parte del Gobierno o de los partidos mayoritarios ". **TORRES BOURSAULT (Leopoldo) "***La División de Poderes en la España de Hoy, en Sistema",* Revista de Ciencias Sociales. Nº. 117 Madrid. España. Noviembre.1993, pag. 23

un Estado Social[8]. Esto ha convertido a la Administración en una especie de "cuarto poder"[9], que insistimos, obliga a replantear la estructura organizativa, o si se quiere los simples elementos organizativos de la división, pero que en modo alguno destruyen su esencia[10]. La génesis de nuevos centros de imputación, de actuación, deliberación o control, revela tan sólo que las estructuras de poder se ajustan a los cambios sociales y a las exigencias eficientistas de nuestro tiempo, que a la vez se cuidan bien de crear el contrapeso, con el que se interrelacionan de manera incesante[11].

Y aún dentro de los órganos constitucionales de control, encontramos dificultades para un engarce pleno dentro de la división horizontal de poderes. No puede ser menos ejemplificante el caso de la Sala Constitucional, que, siendo parte del Poder Judicial, se impone en su función a todos los poderes constitutivos del Estado. Su papel dentro de esta distribución funcional, y más aún, su legitimación para el ejercicio de esas atribuciones, es un aspecto que escapa a la concreción de este apartado, sin embargo, es imposible resistir la tentación de un pequeño comentario, y en ese caso, nada mejor que hacerlo en compañía de don Manuel GARCÍA PELAYO, quien con su profundidad característica sostiene que este

---

[8] **GARCÍA MACHO (Ricardo)**: "*Problemática de la División de Poderes en la Actualidad"*, en Revista de Estudios Políticos. Nº 53. Nueva Época. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. Setiembre-Octubre. 1986, pag. 183.

[9] La expresión se toma del profesor Miguel SÁNCHEZ MORÓN, cuando afirma que "... lo cierto es que la Administración ha dejado de ser una nueva prolongación orgánica del Gobierno de turno. La independencia profesional del funcionario y la imparcialidad administrativa, sancionada por las normas jurídicas, convierten a la Administración en una especie de cuarto poder". **SÁNCHEZ MORÓN (Miguel)** " *El Control de las Administraciones Públicas y sus Problemas".* Editado por el Instituto de España. Espasa. Calpe. Madrid. España. Primera Edición. 1991, pag.32.

[10] El maestro GARCÍA DE ENTERRÍA ha delatado con su característica propiedad, la inadecuación de la Administración bajo el esquema tradicional de la división de poderes, y así ha dicho: "La idea del Estado que acabamos de exponer no aloja en su estructura, ni propiamente le da cabida, a una Administración como la que el Estado absoluto había erigido en su postrera fase y como la que hoy estamos habituados a conocer. Dentro del esquema "Ley, Tribunales y orden público", sólo esto último refiere una porción mínima de esta Administración, cuyo más importante complejo de funciones es remitido íntegramente en esta concepción al juego libre del concurso social". *Revolución Francesa y ...*, op. cit., pag. 35.

[11] En nuestro siglo se ha abandonado la figura del individuo en su calidad singular y particularizada, como eje central y único sobre el que gira todo el ordenamiento jurídico. La persona sigue manteniendo su papel determinante, como debe ser, pero la óptica de aquellos derechos fundamentales de otrora, ha cambiado sustancialmente, pues en los tiempos que rigen, la atención se enfoca sobre las libertades económicas, la pertenencia y participación política efectiva, la intimidad y los derechos prestacionales, como derivación de los sociales. Hay un nuevo enfoque hacia el grupo organizado, que supera la visión del individuo como sujeto aislado. Esto quizá se deba a que los anteriores, en mucho han sido alcanzados, por lo que siendo los fundamentales, derechos de conquista, en enrumban ahora por nuevos derroteros que garanticen el bienestar de la persona en relación. Sobre este aspecto puede verse la obra de BOGNETTI (Giovanni): La Divisione Dei Poteri. Saggio Di Diritto Comparato. Giuffrè Editore. Milán. Italia. Primera Edición. 1994. Pag. 15 y ss.

órgano, aparte de garantizar la hegemonía de la norma suprema y de proteger los derechos fundamentales de las personas, asegura la vigencia de la distribución de poderes establecida en la Constitución y perfecciona la vigencia del Estado de Derecho, pues entre otras cosas, impide la concentración del poder y coadyuva a su ejercicio armónico, complementando así la función garantizadora de la jurisdicción contencioso administrativa[12]. La Sala Constitucional es entonces necesaria para garantizar -entre otras cosas- el equilibrio de poderes, pues en muchas ocasiones se descubrió también que el propio parlamento era capaz de convertirse en despótico, con sus potestades exorbitantes e inmunes al control judicial común (nunca tan peligroso y amenazante como en la actualidad de nuestro tiempo en la que acecha o se entroniza silenciosamente como instrumento efectivo de los totalitarios y megalómanos). Se comprobó que la infalibilidad de las leyes no era sino otra ilusión, por cuanto el legislativo también comete excesos, máxime cuando se subordina a un poder político incontrolado, pues en tal caso las dictaduras mayoritarias de un cuerpo representativo pueden ser tan opresoras como una dictadura del ejecutivo. Es en este marco en el que surge la justicia constitucional para sumarse y fortalecer a la ya imperante justicia administrativa[13]. En cuanto al segundo aspecto (su legitimación) , sólo se explica por la preeminencia jurídica revitalizada que se da con el resurgimiento de los derechos fundamentales, lo que provoca que en el régimen actual, la Sala Constitucional (y si se quiere los Tribunales en sus últimas instancias [14]), posea un amplio poder (que algunos catalogan de omnímodo), lo cual es lógico y razonable, en cuanto son ellos los intérpretes de la norma fundamental y del ordenamiento (que también les abarca y somete), y en tanto se constituyen (junto al contencioso) como los garantes de la juridicidad del comportamiento público. Alguien debe cerrar la cadena de controles, y esa tarea no corresponde más que al Juez, ya sea ordinario o constitucional, por cuanto a él le fue depositada (por Norma Suprema) la función jurisdiccional, así como la

---

[12] *El " Status" del Tribunal Constitucional*, en Revista Española de Derecho Constitucional. Vol. I. Nº 1. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. Enero- abril. 1981. Pag. 11 y ss. Asimismo puede verse SCHNEIDER (Hans-Peter): *Jurisdicción Constitucional y Separación de Poderes*, en Revista Española de Derecho Constitucional. Año 2. Nº 5. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. Mayo- Agosto. 1992. Pag. 35 y ss.

[13] **CAPPELLETTI (Mauro)** - "*¿Renegar de Montesquieu? La Expansión y la Legitimidad de la "Justicia Constitucional"*, en Revista Española de Derecho Constitucional (REDC). Nº 17. Centro de Estudios Constitucionales. Año 6. Mayo-Agosto. 1986, pag. 27.

[14] En cuanto contralores de toda la actividad pública que esté al alcance de su mano, que no es otra que la sometida a parámetros jurídicos o susceptible de serlo.

interpretación y aplicación de la Constitución, cuyo objetivo esencial no es otro que hacer prevalecer el Derecho en la conducta humana, en procura y garantía de su libertad y bienestar, y como instrumento útil para la prosecución de la justicia. De lo contrario seguiríamos buscando y colocando de manera indefinida al contralor del contralor, con riesgo grave de la burocratización e ineficiencia del sistema, que probablemente se difuminaría en alambicados mecanismos recursivos, a contrapelo de un adecuado equilibrio de funciones[15].

Esto, en modo alguno debe verse como gobierno de los jueces, o como un "deslizamiento del Estado de Derecho hacia un Estado de vías o medios judiciales"[16], pues entre sus múltiples carencias está, el poder de iniciativa de la actividad pública (salvo que esté dispuesta por disposición normativa, en cuyo caso la iniciativa no sería del Juzgador sino de la norma).

Hay quienes tratan incluso de negar la autoridad de los tribunales sobre el Legislativo y Ejecutivo a partir del envolvente criterio de la legitimidad popular, olvidando, al menos para el caso concreto de la justicia administrativa, que la Administración Pública, como persona jurídica, es servicial y subordinada al Derecho, y en muchas ocasiones no elegida directamente por el pueblo; en consecuencia, al margen de la representación directa. Pero en todo caso, teniendo o no legitimidad democrática, está claro que hay un esfuerzo por confundir dos esferas diversas, pues la existencia de tal representación no justifica en todo caso la inmunidad en el control[17]. Más aún, por esa legitimidad democrática viene

---

[15] No obstante, para algunos "la última decisión vinculante no está, por principio, entregada al Juez, sino que, según la materia, está confiada al *Juez y a la Administración*". A partir de allí crean una amplia gama de conductas, que por estimarse discrecionales, están fuera de la justiciabilidad administrativa. Al respecto véase IMBID IRUJO (Antonio): *La Relación entre los Poderes del Estado en la Reciente Dogmática Alemana*, en Revista de Administración Pública. Nº 115. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. Enero- Abril. 1988. Pag. 420-421.

[16] La expresión es propia de la doctrina alemana y del cuestionamiento que al respecto realiza Antonio EMBID IRUJO, en su artículo *La Relación entre los...*, op. cit., pag. 409.

[17] Ya en su momento se encargó de ponerlo en claro el autor León DUGUIT, cuando refiriéndose al Tribunal de la Constitución dijo: " Si se admite el principio formulado por la Asamblea Constituyente, si se admite la autonomía, la independencia absoluta del poder judicial, si se considera que emana, como el poder legislativo, directamente del pueblo soberano, debe ser el igual del poder legislativo y, como él, estar subordinado únicamente a la Constitución... igual que el legislador no está sometido a otra autoridad que la Constitución, el juez no debe estar subordinado a otro poder que el constituyente. El respeto de la Constitución debe estar garantizado por el equilibrio de estos dos poderes iguales e independientes. Imponer al Juez la obligación de aplicar una ley inconstitucional es declararle inferior al legislador, es situarle bajo su dependencia; es violar el principio de separación de poderes". DUGUIT (León):" *La Separación de Poderes y la Asamblea Nacional de 1789*. Publicación realizada en Francés en el año de 1893". Traducida por Pablo Pérez Tremps. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1996., pag. 104

doblemente exigido el control, que como se sabe, no se agota en lo político o social[18], pese a la universalidad con que se proclama este último respecto de los "actos u omisiones del Gobierno". Cualquiera esfera de Poder, con legitimación democrática o no, está sometido al Derecho y a la Constitución[19]. Por ello hay quien señala que el verdadero fundamento de la división de poderes está en el Poder nomocrático[20]. Pero como ya he dicho, este es un tema que nos lleva directo a terrenos que no son los que ahora recorremos.

Volviendo a nuestro tema central, tenemos como consecuencia que los hechos y la normativa actuales evidencian que los Poderes han evolucionado, crecido y complicado, por lo que para automantenerse y lograr sus funciones básicas, las Administraciones (diversas de las políticas, legislativas y jurisdiccionales) han tenido que adoptar y adaptar nuevas esferas de actuación que se reflejan en conductas diversas hasta la fecha ignoradas o desapercibidas[21]. Y estas nuevas manifestaciones de la función administrativa, por su propia naturaleza servicial[22] y algunas veces adjetiva o de apoyo, está sometida al Derecho y debe ser reflejo de él, lo cual atribuye también a ese nuevo quehacer público, la característica de jurídico, y al serlo está sometido al control del Juez, como encargado de proteger los derechos

---

[18] Precisamente, de no ver a la Constitución como única y exclusiva herramienta jurídica, sino también como mecanismo y fenómeno político, es donde se extrae más claramente, la necesidad de controles pluridimensionales. Al respecto véase **DE AGAPITO SERRANO** - "*Libertad y División de Poderes. (El "Contenido Esencial" del Principio de la División de Poderes a partir del pensamiento de Montesquieu)".* Editorial Tecnos. Madrid. España. Primera Edición. 1989, pag. 165.

[19] Como bien señala el Prof. SANTAMARÍA PASTOR, la revolución liberal francesa tuvo como fundamento el de la soberanía de la ley, es decir la obligación de todos los órganos del Estado de atenerse a sus mandatos; en definitiva, la **juridificación del aparato estatal**. Y esta fundamentación llevaba implícita una sutil consecuencia, pues "el propio dogma de la soberanía de la ley exigía, por coherencia, la aceptación de que algún órgano (o serie de órganos) estatal controlara el ajuste de la actividad estatal a los preceptos legales. A un control político, pues, se sumaba un control jurídico". Sobre este aspecto puede verse su obra Fundamentos de Derecho Administrativo. Tomo I. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. España. Primera Edición. 1991. Pag. 888.

[20] SÁNCHEZ AGESTA (Luis): *División de Poderes y Poder de Autoridad del Derecho*, en Revista Española de Derecho Constitucional. Nº 25. Año 9. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. Enero- abril. 1989. Pag. 13-14.

[21] Así Adolfo CARRETERO PÉREZ nos habla de un cambio en el sistema, en cuanto se pasa de una correspondencia singular entre órgano y función, a una pluri-imputación de funciones en cabeza de un mismo órgano. Véase su artículo *La Versión Constitucional de la División de Poderes y Funciones del Estado*, en Actualidad Administrativa. Nº 5. Editora General de Derecho S.A. Madrid. España. 30 nov-5 dic. 1985. Pag. 309.

[22] Se dice servicial, en cuanto está al servicio de la comunidad, sin ser representante de ella. Sobre este aspecto véase GARCÍA DE ENTERRÍA (Eduardo) y FERNÁNDEZ RODRIGUEZ (Tomás Ramón): Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Editorial Civitas. Madrid España. Sétima Edición. 1995. Pag. 30.

e intereses de las personas y hacer cumplir la ley. Como se ve, esta concepción lleva implícito un giro que no podemos dejar pasar de manera subrepticia. En efecto, ya se habrá notado el importante cambio en la concepción que del Juez actual se tiene con respecto a la idea que del mismo habían forjado los teóricos del siglo XVII y XVIII. Éste aplicaba la letra de la ley, en un simple proceso de subsunción; ahora, en cambio, como órgano parte del Poder Judicial, ve fortalecido en grado máximo sus poderes respecto de las demás funciones básicas del Estado, al someterlas todas, o en su mayoría, al imperio del Derecho.

Este nuevo rol, en modo alguno choca con el principio al que nos venimos refiriendo, pues lo que no se ha comprendido, es que el principio de división de poderes tiene, además de todo, un claro carácter instrumental, de atribución de funciones soberanas a diferentes centros de poder, lo que lleva a un ejercicio mutuo de control y a un límite recíproco, generado en una interrelación constante[23]. El principio se dirige, entre otras cosas, a una racional distribución de funciones soberanas. Actualmente la "división" en vez de dirigirse a los poderes, debe enfocarse hacia los órganos constitucionalmente dados, con un complejo de competencias propias. No se trata de una mera interpretación mecánica, sino de un principio entendido de una forma elástica, dinámica y ante todo evolutiva, donde los órdenes del poder se amplían o reducen según las circunstancias y momento histórico[24]. Bajo esta tesitura, no tiene cabida la rigidez, pues se trata de una atribución prevalente de funciones no monopolizada, antes que un congelamiento orgánico. Es, desde este ángulo y en palabras de ESCRIBANO[25], un principio organizativo instrumental por el que se realiza una atribución funcional, prevalente y no exclusiva. Es un principio que no subsiste si no se adapta.

El sostenimiento de una separación rígida de funciones y órganos conlleva directamente a la concentración del poder en uno de ellos, pues dependiendo de la amplitud

---

[23] Así RUIZ DEL CASTILLO habla de un elemento estructural, interno y sustantivo que permite alcanzar la libertad como elemento subyacente y sustancial. Aquel es la estructura levantada para ésta. RUIZ DEL CASTILLO: "La Doctrina de Montesquieu. Valor Actual, en El Principio de Separación de Poderes". Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid. España. Primera edición.1951, Pag. 24

[24] Una concepción moderna de la separación de poderes obliga a afirmar que aquella no es absoluta y la conveniencia de establecer una diferenciación funcional con una adscripción específica de cada función a órganos determinados, para que pueda ser un hecho la eficacia de la acción del órgano. GASCÓN Y MARÍN (José): *Aplicación del Principio de la Separación de Poderes en el Derecho Constitucional Moderno*, en El Principio de Separación de Poderes. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid. España. Primera Edición. 1951. Pag.73.

[25] ESCRIBANO COLLADO: " Voz Deber", en la Enciclopedia Jurídica Básica. Tomo II. Editorial Civitas. Madrid. España. Primera Edición. 1995, pag. 36.

en su espectro funcional; de la incidencia más o menos directa de sus decisiones en la sociedad y de su dinamicidad en el ejercicio del mando, tendrá mayor o menor preponderancia sobre los otros. El resultado inmediato de esta concepción ha generado entonces un resquebrajamiento de la comprensión clásica de principio (que según vimos ha llevado a algunos al equívoco de sostener su inutilidad o decaimiento), con una tendencia creciente a la expansión de las funciones ejecutivas en detrimento de las legislativas y una "lucha" que se ha catalogado como " idílica por parte del poder judicial, para actuar como último baluarte de la función controladora, por vía del fiel cumplimiento de los postulados del estado de derecho "[26]. Fue esto lo que ocurrió en el período posrevolucionario, y es esto lo que se ha venido acentuando, con el transcurso de las décadas. Resultado que por demás no es sorpresivo, ya que se había denunciado y previsto desde finales del siglo XIX bajo la acuciosa y sólida opinión de León DUGUIT, quien al criticar con severidad la corriente que adoptara la Asamblea Nacional Constituyente de 1789, afirmó: " Empapada en el espíritu clásico hecho de deducciones lógicas, seducida por los principios absolutos, confiada en su omnipoder, en su virtud mágica, no lee en *El Espíritu de las Leyes* más que las fórmulas generales y sintéticas; no ve ... que una división absoluta desemboca fatalmente en la concentración de todos los poderes en uno sólo; ... no ve, en fin, que, en la continuación del Capítulo VI, MONTESQUIEU muestra, con claridad meridiana, que una íntima solidaridad, que una colaboración constante debe unir a los diferentes poderes del Estado..."[27]

Quienes sostienen esa posición rígida de la separación de poderes, pretenden ignorar que el poder ejecutivo, y más concretamente, la Administración Pública, no se ha limitado nunca a la mera actuación (ejecución) práctica de los preceptos normativos, sino que ha tenido y tiene por objeto, la adaptación de la norma abstracta a la multiplicidad imprevisible

---

[26] **QUIROGA LAVIÉ (Humberto)**: "*Sobre la Teoría de la Representación Popular y la División de los Poderes de Gobierno"*. En Libro en Homenaje a Manuel García Pelayo. Tomo I. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 1980, pag.85". En igual sentido se manifiesta Emilio SUÑE LLINAS, para quien el sistema elaborado por Montequieu " ha sido seguido de manera demasiado formal y lineal por las Constituciones, hasta el punto de que a menudo ni responde a la dinámica auténtica del poder, ni lo distribuye, ni comporta siquiera que la Constitución sea soberana, al originar tales desequilibrios que sólo un órgano del Estado es auténticamente depositario de la soberanía, al estilo de lo que sucedía con el príncipe descrito por BODIN." Véase su artículo titulado *Sobre el Concepto de Potestad*, que se publica en el Libro en Homenaje al Profesor José Villar Palasí. (Coordinado por Rafael Gómez-Ferrer Morant). Editorial Civitas S.A. Madrid. España. Primera Edición. 1989. Pag. 1368.

[27] Op. Cit., pág. 14.

de la vida[28]; está obligada a implementar por iniciativa propia, bajo un Estado Social de Derecho, el desarrollo de políticas y servicios, en procura de satisfacer las necesidades básicas y de alcanzar y mantener el equilibrio social. Bajo esta perspectiva, su función no es tan sólo la de un aparato público restrictivo o condicionante del actuar privado (conducta limitativa), sino también la de instrumento generador de las condiciones básicas y necesarias para el buen ejercicio de esa libertad y acción privada (actividad prestacional). Y en ambas funciones se encuentra interrelacionado con los demás poderes, a los cuales no puede abstraerse, al menos en la función central y básica de aquellos. La Administración Pública, aún con ese desdoblamiento funcional, y más aún con él, está sujeta al Derecho y al poder jurisdiccional del Juez, no con irrespeto de la división de poderes establecido, sino en cumplimiento pleno del mismo. El Judicial no puede ni debe renunciar a su función jurisdiccional, creando zonas de inmunidad donde no existen.

Esa Administración Pública socializadora de nuestro tiempo (y en especial el Ejecutivo) requiere de una fiscalización y de controles adecuados, que no se agotan (porque no son suficientes) en el poder revisor o anulatorio del Juez frente a una conducta ya y necesariamente desplegada[29]. El control jurisdiccional ha de ser más amplio, no para entrabar el cometido de la Administración, sino para garantizar el efectivo cumplimiento de su finalidad, entre las que se encuentra además la eficacia y la eficiencia, y, ante todo, para proteger aquellos derechos e intereses legítimos del particular que le han sido atribuidos directamente por el ordenamiento jurídico (mediante norma legal o infralegal), y algunas veces, por la propia Administración (a través de acto o contrato). Si el ordenamiento jurídico establece los fines en el ejercicio de la actividad administrativa, y regula la estructura congruente para el logro de tales fines, el Juez Contencioso está llamado a confrontar el acomodamiento jurídico de unos y otros con la actividad concreta de la Administración Pública, lo que directamente lleva a que el control jurisdiccional de ésta última, está integrado, como pieza esencial, a la estructura finalista de poder atribuida por el

[28] DE AGAPITO SERRANO: op. cit., pag. 135.

[29] Como tampoco se agotan en el solo control judicial, pues está claro que debe perfeccionarse todo el sistema de controles de la Administración Pública, en virtud de la atrofia de algunos de los instrumentos imperantes, en los que, por desgracia, el judicial no está excluído, como producto de su lentitud, deficiencia e ineficacia del sistema vigente. Sobre el problema general de los controles de la Administración Pública y acerca de este aspecto específico puede verse SÁNCHEZ MORÓN (Miguel): op. cit., pag. 14 yy ss.

ordenamiento. Tal y como se ha dicho: "La justicia es una función del Estado y, al mismo tiempo, un requisito estructural de su condición de Estado de derecho"[30], y ese Estado de Derecho -en palabras de KRÜGER- "no significa sólo que el Estado esté controlado por el derecho, sino que también existe el derecho a controlar el Estado".

De esta forma, es claro que el Poder Judicial no tiene reservas para desplegar su función en la universalidad de la conducta administrativa en cuanto se encuentre sometida a la juridicidad y por ende reducida ante ella (como lo dispone el 153 de la Constitución), pues para ello no hay obstáculo jurídico-político en una supuesta división de poderes, que en su concepción teórica nunca ha sido tal ("división" rígida), pues de manera inversa la propia Constitución exige con carácter de fundamental, la tutela general e indiscriminada de los derechos e intereses de toda persona. Por el contrario, es para la protección de tales derechos, y en especial de los fundamentales, que se hace necesaria una distribución de funciones (esa mal llamada "separación de poderes"), que impida la concentración del poder y permita al Judicial, de manera independiente, juzgar la conducta administrativa de los otros poderes, a fin de garantizar la legalidad de esta y la tutela efectiva de los derechos del particular. Como señaló TARGET al aprobarse la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano:

> "*Los derechos del hombre sólo estarán asegurados si los poderes públicos son distintos y están sabiamente distribuidos*"[31].

Si se pretende y se ordena que todos los poderes públicos tutelen de manera efectiva los derechos e intereses de toda persona, y especialmente el Poder Judicial, es imprescindible la preexistencia de una distribución de funciones y poderes que permita su control por parte del Juez. Así, en la medida en que se realice una efectiva y eficaz justicia administrativa, estarán los Tribunales garantizando y reafirmando dicha distribución. Y es que corresponde al Juez en último término, garantizar la efectividad de tal principio. "La misión central del poder judicial reside en controlar tanto al legislativo cuanto, sobre todo, al ejecutivo. Representa un instrumento de precisión, un broche de cierre, en el conjunto de los poderes públicos que

---

[30] **ARAGÓN REYES (Manuel)**: "*El Control como Elemento Inseparable del Concepto de Constitución".* En Política y Sociedad. Estudios en Homenaje a Francisco Murillo Ferrol. Vol. I. Centro de Investigaciones Sociológicas. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. Primera Edición. 1987, pag. 314".

[31] Acta del 26 de agosto de 1789. Citada por DUGUIT (León): op. cit., pag. 6.

la Constitución reconoce; la jurisdicción preserva el equilibrio de los tres poderes"[32]. En tanto que el Juez garantice la supremacía de la ley frente a las actuaciones de la Administración Pública sometidas al régimen de juridicidad (cualquiera sea su manifestación), se logra un adecuado equilibrio y un verdadero control de poderes, que produce además la racionalidad y eficiencia de la actividad estatal, pues contrario a lo que se dice, el respeto del ordenamiento jurídico no está divorciado de la eficacia y eficiencia[33]. Ampliando la idea del Profesor Don Manuel ARAGÓN, podemos decir, que la vigencia del ordenamiento jurídico (no sólo de la Constitución) depende de su efectividad, de su "capacidad de realización", que no se concibe en un Estado social y democrático de derecho, si no descansa en la existencia y efectividad de los controles, que, para este caso, corresponden al Juez contencioso-administrativo[34]. Es claro pues, que la legitimidad derivada del origen democrático exige legitimidad en el ejercicio del poder, que sólo se garantiza bajo el control jurisdiccional[35]. El ejercicio de la función jurisdiccional contencioso administrativa, antes que menoscabar el prestigio y eficacia de la Administración, coopera con el mejor desenvolvimiento de las funciones administrativas, y, afirma y cimenta la autoridad pública.

En síntesis, no se suplanta cuando se revisa, no se interfiere ni se inmiscuye (antijurídicamente) cuando en un proceso se ejerce la función de tutela jurisdiccional otorgada por la propia Constitución y en garantía de los derechos del administrado. La

---

[32] BARNÉS VAZQUEZ (Javier): *La Tutela Judicial Efectiva en la Grundgesetz (Art. 19.IV)*. En el Libro conjunto titulado: La Justicia Administrativa en el Derecho Comparado. Editorial Civitas en relación con la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Madrid. España. Primera Edición. 1993. Pag. 144.

[33] En este sentido consideramos que las posiciones doctrinales que se han mantenido hasta el momento como antagónicas, verdaderamente no lo son, pues el respecto de los derechos e intereses legítimos no choca ni reduce la eficacia y eficiencia de la Administración. Ambas tesis son complementarias. Es por ello que, la legislación (que no debe ser abrumadoramente numérica) ha de comprender los diversos factores sociales, económicos y políticos en juego, con vocación de generalidad y permanencia, con la máxima pulcritud técnica y ante todo con miras al resultado del objeto y actividad regulada. Acerca de las dos tendencias del control judicial sobre la Administración Pública, puede verse SÁNCHEZ MORÓN (Miguel): op. cit., pag 16.

[34] Op. Cit., pag. 302. El mismo autor señala al proponer una considerable ampliación de los controles que: " Junto al control de constitucionalidad de las leyes, de los reglamentos y de otros actos del poder público e incluso del poder social o de los particulares (*drittwirkung)* o a la resolución jurisdiccional de los conflictos de atribuciones o de competencias, la ampliación o eficacia de los controles se manifiesta en la completa sumisión de la Administración a la ley, con la desaparición de ámbitos exentos, en el establecimiento de nuevas instituciones de fiscalización... ".

[35] **DELGADO BARRIO (Javier)**: "*El Principio de Efectividad de la Tutela Judicial en la Jurisprudencia Contencioso Administrativa, en La Protección Jurídica del Ciudadano"*. Estudios en Homenaje al Profesor Jesús González Pérez. Tomo II. Editorial Civitas S.A. Madrid. España. Primera Edición.1993, pag. 1189.

Administración procura (o debe procurar) la satisfacción de los intereses colectivos, el Juez revisa que las medidas adoptadas (o en su caso no adoptadas) para tal finalidad, se ajusten al ordenamiento jurídico, sin violación ilegítima de los derechos e intereses de la persona (individual o colectiva). La primera actúa (o deja de hacerlo), el segundo controla externamente (muchas veces a posteriori) tan sólo la juridicidad, luego de que ha nacido un conflicto concreto, que, por circunstancias diversas, dio el salto al ámbito judicial.

II. La Tutela Judicial Efectiva como norte del Contencioso Administrativo.

La tutela judicial efectiva[36] aplicada al contencioso-administrativo, tiene como fin último garantizar una protección judicial adecuada de los derechos e intereses legítimos del particular frente a cualquier conducta antijurídica de la Administración Pública. Bajo esa perspectiva exige a los órganos jurisdiccionales un triple cometido: una función de prevención general de la norma jurídica, coadyuvando a su voluntario cumplimiento mediante la clarificación de la ley y el efecto ejemplificador; una tarea de aplicación subsidiaria y coactiva de la norma violada, restaurando el orden jurídico conculcado; y una labor de protección de los derechos subjetivos o intereses violados o en trance inminente de violación, impidiendo o mitigando su efectiva damnación[37].

De esta manera puede afirmarse que encontramos tres niveles fundamentales en su contenido: la tutela judicial como derecho subjetivo; como vía de comunicación entre el poder jurisdiccional, el particular y la Administración Pública, y como garantía institucional[38]. Como tutela individual está dirigida al o las personas eventualmente lesionadas. Lo anterior no implica que, por estar concentrado en los derechos e intereses

[36] La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado e integrado este derecho fundamental a nuestro bloque normativo a través de una línea jurisprudencial consolidada, según consta en los siguientes pronunciamientos: Voto Nº 1739-92 del 8 de mayo de 1992; Voto Nº 06325-2000 del 19 de julio de 2000; Voto Nº 2005-06224 del 25 de mayo de 2005; Voto Nº 2006-09571 de las 16:14 horas del 5 de julio de 2006; Voto Nº 05715-2011 del 10 de mayo de 2011; y Voto Nº 07166-2012 del 30 de mayo de 2012.

[37] ALBACAR LÓPEZ (José Luis): *Contenido y Alcance del Derecho a la Tutela Jurisdiccional*, en el libro conjunto titulado: El Poder Judicial. Vol. I. Dirección General de lo Contencioso del Estado. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. España. Primera Edición. 1983. PP. 418-419.

[38] BARNÉS VÁZQUEZ (Javier): op. cit., pag 142.

legítimos, esté excluido cualquier control objetivo de la legalidad y, ante todo, cualquier conducta administrativa.

Nótese que se habla de protección judicial en el **ejercicio** de los derechos, lo que significa que no sólo de trata de un deber de respeto por parte de la Administración, de los jueces y del legislador, sino además un deber de actuación, en tanto exige una interpretación de las normas (**sobre todo procesales**), acorde con el derecho fundamental. No se limita a la tutela frente a la lesión ya causada, sino que va más allá, señalando la tutela en el ejercicio., con lo que reconoce la protección de las situaciones de ventaja para el administrado.

Así, entendiendo el derecho e interés legítimo contemplados en el 49 constitucional, como el verdadero objeto del proceso (a través del cual se busca su tutela), encontraremos el punto de enlace preciso, que no es otro que la pretensión; lo que a su vez descompone su efecto en una doble vertiente, pues en cuanto derecho o interés legítimo aparentemente engarzado a la pretensión en la fase inicial, servirá como legitimación procesal, y en cuanto titularidad material efectiva vinculada a la pretensión definitiva de la demanda, fungirá como presupuesto de una sentencia de fondo favorable. Más aún, esta exigencia de protección al derecho o interés material puede reflejarse más allá del proceso en sentido estricto, puesto que habrá circunstancias que obligan a su protección de previo a la existencia del mismo (con la tutela cautelar anticipada, por ejemplo) o luego de que se haya definido el conflicto y aparentemente fenecido el proceso (como ocurriría con las incidencias propias del derecho ya declarado en sentencia y en proceso de ejecución).

Ha de advertirse, eso sí, que la existencia de ese derecho o interés legítimo material, no se hace depender en modo alguno del artículo 49 constitucional, pues éste es el encargado de su tutela, no de su creación. Sin perder de vista que la Constitución crea por sí misma un conjunto de derecho e intereses (algunos de los cuales denominamos fundamentales), lo cierto es que normalmente corresponde al ordenamiento infra constitucional la creación de derechos y la tipificación intereses, de allí que su delimitación, por lo general, no es un problema constitucional, sino un problema de interpretación de legalidad ordinaria[39].

De lo expuesto podemos puntualizar en varias afirmaciones que saltan a la vista:

---

[39] **ALONSO GARCÍA (Enrique)** - "*El Artículo 24.1 de la Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Problemas Generales y Acceso a los Tribunales"*, en la obra conjunta Estudios Sobre la Constitución Política. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría. Tomo II. Madrid. España. Civitas. 1991, pag. 1008.

1. Que el derecho a la tutela efectiva es un derecho mucho más amplio que el derecho al libre acceso a los tribunales.

2. Que el derecho a la tutela efectiva no es el derecho a la acción en sentido concreto.

3.- Que el derecho a la tutela efectiva cubre implícitamente el derecho a la jurisdicción.

4.- Que la tutela judicial efectiva exige la protección y defensa de todos aquellos derechos e intereses, legítimos y materiales, que el propio ordenamiento jurídico haya atribuido a la persona.

5.- Que la tutela judicial efectiva implica la necesaria judicialización de todos los conflictos relacionados con derechos e intereses legítimos, de tal forma que no haya ningún sector del ordenamiento ajeno a la posibilidad de un pronunciamiento judicial. Así, no deberán excluirse pretensiones por razón de su fundamento o por la manifestación particular de la conducta administrativa, contra la cual se manifiesta inconformidad.

Ya decíamos antes que cualquier instituto del contencioso administrativo que se comente, requiere de la imprescindible cita de la tutela judicial efectiva. Y si no basta con ver la vía previa; el acceso a la jurisdicción y la materia de recursos; el objeto del proceso; las medidas cautelares; el contenido y alcance de la sentencia; el recurso de casación, así como la ejecución del fallo final. Todos, absolutamente, se relacionan con la tutela judicial efectiva[40], sobre las que irradia una influencia por cierto positiva y renovadora, pues contrastados con la realidad cotidiana, revelan una imprescindible necesidad de cambio, que permitan la ampliación y **FORTALECIMIENTO DE SU FUNCIÓN Y FINALIDAD EN EL PROCESO**. Así, en el decir del Profesor Don Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA[41] tenemos que la decisión administrativa previa; la necesidad de agotar la vía administrativa antes de acceder al Tribunal; la abreviación de plazos para recurrir y la exigencia de legitimaciones

[40] Don Jesús GONZÁLEZ PÉREZ restringe los efectos de la tutela jurisdiccional a tres momentos distintos: "primero, en el acceso a la justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia". **GONZÁLEZ PÉREZ (Jesús)**: "*El Derecho a la Tutela Jurisdiccional"*. Editorial Civitas. Madrid. España. Segunda Edición. 1989, pags. 43 y ss.

[41] Cfr. su artículo *"Los Ciudadanos y la Administración: Nuevas Tendencias en Derecho Español",* contenido en su libro Hacia Una Nueva Justicia Administrativa. Editorial Civitas. Madrid. España. Segunda Edición. 1992. Pag. 63 y ss.

cualificadas, son temas que están afectados por la tutela judicial efectiva. Es preciso paliar -señala- la técnica de la ejecutoriedad previa con una panoplia de medidas cautelares del Juez contencioso; se ha de convertir la vía previa de preceptiva en facultativa; deben superponerse a los plazos procesales impugnatorios de carácter preclusivo, los plazos de prescripción de los derechos de fondo; con respecto a la legitimación, no es trascendente hacer el distingo entre interés legítimo y derecho subjetivo, bastará ubicar un " derecho reaccional " para entender legitimado al particular accionante. Continua diciendo que han de generalizarse los fallos condenatorios, abarcando incluso las condenas de hacer ; opina que debe aplicarse el concepto procesal de cosa juzgada que impide reabrir el proceso decidido, y en consecuencia reproducir total o parcialmente el acto anulado o a la emisión de otros actos de contenido incompatible, que de darse, serían eliminados a través de incidentes simples de ejecución, y por último indica que, siendo que en el derecho a la tutela judicial efectiva está contenido el derecho a obtener ejecución de los fallos (pues ese derecho fundamental no se satisface tan sólo con el fallo declarativo), deben introducirse nuevos instrumentos de ejecución, tales como los comisarios.

Pero está claro que la protección judicial efectiva del ciudadano impone una extensión universal del control administrativo, que obliga a la protección de cualquier derecho o interés legítimo, sin miramientos de la específica conducta administrativa que genera su lesión. Esto implica que cualquier disposición normativa que prohíba, cierre o limite el "recurso" contencioso a sólo determinadas decisiones o conductas, está viciada por inconstitucionalidad sobrevenida[42]. Ello obliga a un control sobre los elementos jurídicos de la discrecionalidad y la apertura del contencioso a la inactividad administrativa, con posibles fallos condenatorios y sustitutivos. Si el mandato constitucional impone la tutela de los derechos e intereses legítimos, el Juez debe intervenir para la protección de aquellos, sea cual fuere el comportamiento administrativo que produjo su lesión. Ya se trate de un acto administrativo, de una vía de hecho, de una disposición o bien de la inactividad administrativa, puede el ciudadano acudir ante el Juez de lo Contencioso exigiendo el cumplimiento pleno de la protección judicial eficaz y plena como derecho fundamental.

[42] GARCÍA DE ENTERRÍA (Eduardo): *"Los Ciudadanos y la Administración..."*, op. cit., pag. 63.

Conforme a lo anterior, puede decirse que la tutela judicial efectiva exige al legislador y al Juez (o Tribunal), un oportuno y amplio acceso a la Justicia (lo que obliga a flexibilizar el agotamiento previo de la vía administrativa y en la mayoría de los casos eliminar como necesario, los requisitos de procedibilibdad y el radio de legitimación procesal); la protección y aseguramiento del derecho o interés pretendido (lo que incide en las medidas cautelares y en el objeto del proceso, que deberán ser igualmente amplios y flexibles, a fin de garantizar la pervivencia del mismo y su posible reconocimiento en una sentencia de fondo, con independencia de la conducta administrativa específica que origina la lesión); una decisión motivada que dilucide la situación jurídica en litigio (lo que exige una ampliación de las potestades del Juez, quien deberá además examinar exhaustivamente las cuestiones planteadas) y la satisfacción plena del derecho reconocido o declarado (lo que impone un serio fortalecimiento de los mecanismos de la ejecución de sentencia).

Lo anterior no obedece más que al conjunto de derechos que la misma jurisprudencia constitucional ha entendido en forma genérica incluida para todo ámbito jurisdiccional, cuando ha dicho que comprende el derecho:

A tener la oportunidad de un procedimiento administrativo con las garantías básicas.

A acceder sin trabas a los órganos jurisdiccionales (derecho de la jurisdicción).

A una tutela cautelar efectiva, lo que implica un judicador abierto, flexible, con sensibilidad humana, atrevido, firme y con real sentido de la urgencia, máxime con la dilación actual de los procesos. En la dinámica vigente, en el que las cautelares definitivas tardan meses en resolverse, la supervivencia de la situación jurídica discutida y la consumación del daño, se juega el todo por el todo con la medida provisionalísima misma. Esa, la que se resuelve en las primeras horas o minutos después de interpuesta ante el estrado judicial.

A alegar en su defensa y proponer las pruebas que estime pertinentes, con expresa prohibición de indefensión.

A obtener una resolución de fondo debidamente motivada y sobre cada uno de los puntos debatidos, siempre que se cumplan los requisitos legales. Con adecuada técnica y conocimiento del derecho.

A una valoración racional, adecuada y profunda de las pruebas, sin prejuicios para ello.

A obtener la resolución en un tiempo razonable, sin dilaciones indebidas.

A una revisión de órgano jurisdiccional superior. Así las cosas, a una segunda instancia cuando el ordenamiento jurídico así lo establezca (que se presenta como opcional salvo para la materia penal), o bien, a través de un recurso de casación, librado de sus formalismos excesivos y distanciado de su inescindible vínculo con la casación francesa, que con grave error se le endilga.

Y a una ejecución del fallo judicial efectivo y pleno.

IV.- La Consolidación de un Contencioso Mixto.

De cuanto va dicho, puede extraerse con facilidad que desde un punto de vista constitucional, el control judicial de la Administración Pública ha dado un importante giro hacia una marcada subjetivación del sistema, que inspirado en la necesaria protección de los derechos e intereses legítimos, por encima de cualquier otra finalidad, permite también un control pleno de la conducta administrativa en cada una y cualquiera de sus manifestaciones, gracias al complemento que brinda la cláusula general del control universal. Podría por ello decirse que la justicia administrativa vigente debe construirse sobre una tendencia preeminentemente subjetiva (protección de la persona), pero no exclusivamente tal. Como señala don Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA "la justicia administrativa es una tutela de derechos e intereses legítimos ... una tutela de posiciones subjetivas... la idea de un proceso al acto ha concluido ... El contencioso no es, en modo alguno, un proceso al acto, o de protección de la sola legalidad objetiva; es un proceso de efectiva tutela de derechos, los del recurrente y los de la Administración (ésta, predominantemente, con potestades en lugar de derechos), entre sí confrontados. No se trata, pues, de un supuesto proceso objetivo o sin partes (...) Todo esto no es más que una consecuencia del reconocimiento del carácter esencialmente subjetivo de la justicia administrativa"[43].

En efecto, habiéndose consolidado la tutela judicial efectiva de todo derecho e interés legítimo, se han derribado las diferentes barreras que impedían el alcance de ciertas conductas, que, por no estar configuradas a través del acto administrativo, o por ocultarse

[43] Hacia Una Nueva Justicia Administrativa. Editorial Civitas. Madrid. España. Segunda Edición Ampliada. 1992. Pags. 60 y 71.

tras el telón de la inactividad, quedaban inmunes al control jurisdiccional[44]. Hoy, la tutela judicial de todo derecho e interés, y el control universal de la conducta administrativa, se convierten en los dos pilares fundamentales sobre los que se levanta el contencioso administrativo, todo ello edificado sobre el terreno de un Estado de Derecho, que además se tilda de Social y Democrático[45].

Por ello, creo que puede hablarse de un contencioso **mixto**, en el que se conjugan las dos corrientes clásicas del contencioso administrativo que hasta hace poco parecían irreconciliables. Por ambas se llegaba quizá a resultados similares, pero en ambas, quedaban al descubierto facetas importantes del quehacer administrativo. Efectivamente, bajo un sistema subjetivo, luego de cumplida la finalidad esencial en la protección de los derechos o intereses legítimos de toda persona, deviene como consecuencia indirecta, la corrección o ajuste de la conducta infractora del bloque de juridicidad. De igual forma, bajo la corriente objetiva quedarían normalmente garantizados los derechos e intereses, luego de resguardada la vigencia y eficacia del ordenamiento jurídico (finalidad primordial de esta segunda concepción).

---

[44] Como señala GÓMEZ- FERRER MORANT "hay que entender que, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, no es admisible la exclusión del conocimiento por la jurisdicción de determinados actos del ejecutivo, por ser contraria a la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas". **GÓMEZ-FERRER MORANT**:*"Derecho a la Tutela Judicial y Posición Jurídica Peculiar de los Poderes Públicos"*, en Revista Española de Derecho Administrativo. Nº 33. Abril-Junio. Madrid. Civitas. 1982, pag. 192 De igual manera se expresa Rafael MATEU-ROS para quien la tutela judicial " supone la necesidad de que las normas procesales provean los mecanismos adecuados para la plenitud de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante cualquier clase de lesión de sus derechos e intereses, sin que puedan existir reductos de inmunidad jurisdiccional ni situaciones jurídico-materiales carentes de una protección procesal suficiente, de tal modo que, en ningún caso, el ordenamiento admita supuestos de indefensión ". **MATEU-ROS (Rafael)** - "*El Derecho Constitucional a la Tutela Judicial Efectiva y el Requisito de la Legitimación*", en Revista de Administración Pública. Nº 98. Mayo- Agosto. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1982, pag. 84.

[45] Como bien señala BREWER CARÍAS: "la forma como están concebidas constitucionalmente la universalidad del control y el derecho ciudadano a la tutela judicial frente a la administración, implica la asignación al juez contencioso-administrativo de *amplísimos poderes de tutela*, no sólo de legalidad objetiva que debe siempre ser respetada por la Administración, sino de las diversas situaciones jurídicas subjetivas que pueden tener los particulares en relación a la Administración. De allí que el contencioso administrativo... no sea solamente un proceso al acto administrativo según la clásica concepción francesa ya superada, sino que está concebido como un sistema de justicia para la tutela de los derechos subjetivos y de los intereses legítimos de los administrados, incluyendo por supuesto, los derechos y libertades constitucionales. Por tanto, no se concibe el contencioso-administrativo sólo como un proceso de protección a la legalidad objetiva, sino de tutela de los derechos e intereses de los recurrentes frente a la Administración". **BREWER CARÍAS** – "*La Universalidad del Control Contencioso Administrativo"*, en la Revista de Derecho Público. Nº 46. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. Venezuela. Abril-Junio.1991, pag. 7.

No obstante, en la puridad de ambos sistemas, se mantienen grietas importantes que no permiten un control plenamente satisfactorio. Así, acudiendo a la vía unilateral subjetiva clásica, se corre el riesgo de que, por la especial característica de la conducta, no se pudiesen detectar intereses o agravios particularizados (individuales o colectivos), pese a la antijuridicidad de la actuación cuestionada. Es el caso de algunos procesos de lesividad, en los que no se detecta un perjuicio directo para el propio ente. En este sentido, hay que recordar que también existen previsiones legales dirigidas a resguardar la seguridad, eficiencia y buen hacer administrativos (que algunos traducen como interés público), de los que no se extrae (al menos en forma directa) una lesión para sujeto o persona alguna, ni siquiera pública, razón por la cual, bajo esta concepción tradicional, quedarían fuera del control judicial. Y es que, bajo el sistema subjetivo clásico, el individuo se convierte en el centro de atención del control jurisdiccional, que pretende a toda costa, la protección de sus derechos e intereses, motivo por el cual, también exige importantes cuotas para la legitimación, que dejan fuera muchos supuestos de gran importancia. Es lo que ocurre por ejemplo en las restricciones o procedimientos interadministrativos o inter orgánicos, que muchas veces son infringidos sin perjuicio para persona alguna, salvo para el interés público[46]. En tal caso, es cuando adquiere importancia la legitimación procesal para órganos y entes del propio Estado, que nos hemos permitido denominar "legitimación institucional".

Por otro lado, a través de la vía objetiva pura, existe el peligro de que queden al descubierto conductas lesivas de intereses legítimos por el hecho de su conformidad (aunque fuere inicial o aparente) con el principio de legalidad. Dentro de esta corriente, es la protección de la legalidad o más precisamente del ordenamiento jurídico, sobre la que fija su atención el Juez Contencioso, en procura de salvaguardar, en vez de los derechos e intereses legítimos, el interés general, motivo por el que la legitimación se rompe, para dar cabida a cualquier ciudadano interesado en la mencionada preservación del ordenamiento. El particular se convierte aquí en mero representante de la legalidad.

Es preciso insistir, aún a riesgo de reiterativo, que, habiéndose disipado cualquier bruma limitativa con respecto a una rígida y equivocada interpretación de la separación de

[46] Se me ocurre como ejemplo concreto una transferencia presupuestaria hecha sin las autorizaciones previas o, por un procedimiento inválido, aunque los fondos hayan sido utilizados en actividades propias de la Administración e incluso con resultados muy favorables.

poderes, y habiéndose confirmado las verdaderas potestades jurisdiccionales del Juzgador en cuanto a la Administración Pública, encontramos ahora una exigencia constitucional que obliga a la tutela efectiva de todo derecho o interés legítimo atribuido a cualquier persona, para lo cual, el Juez Contencioso puede y debe también, controlar la universalidad de la conducta administrativa (sea cual fuere su manifestación), con el fin de someterla al Derecho y a la finalidad dispuesta por el mismo, todo ello en cumplimiento del principio de legalidad. Se trata de un control realizado no sólo desde la perspectiva subjetivo-individual, sino también objetivo-institucional, tomando en cuenta los objetivos supremos del ordenamiento jurídico[47].

Todo lo anterior, no es una mera lucubración o postura doctrinal, sino, el fiel reflejo del artículo 49 Constitucional vigente, que consagra de manera precisa el control universal o pleno de la conducta administrativa, con inclusión de todas sus facetas y exclusión de cualquier zona de inmunidad del comportamiento público dentro del área administrativa. Hubo una intención clara del constituyente, quien siempre tuvo a la vista la estandarización del control jurisdiccional sobre cualquier tipo de conducta administrativa.

Nótese que la Constitución realiza una atribución de competencia específica a efecto de controlar la conducta administrativa, no es una labor que deja a la ley. No se limita a indicar que es una tarea que corresponde a "los Tribunales", sino que indica una jurisdicción concreta, determinada, con lo que, atribuye una reserva competencial a nivel constitucional para la jurisdicción contencioso- administrativa. El legislador no podría entonces disponer que alguna conducta administrativa específica (por estar imbuida de principios especiales, o por cualquiera otra razón) sea del conocimiento de un orden jurisdiccional diverso (civil, laboral, agrario, etc.).

Cuando la norma permite el control de la "función administrativa", adopta sin ambages una fórmula **objetiva** amplia de fiscalización, en la que, como se ha dicho tantas veces, el Juez queda facultado para el control de la totalidad de la conducta administrativa. En efecto, el precepto rompe de tajo con cualquier limitación construida alrededor del objeto contencioso administrativo, pues cuando inserta la generalidad de la "función" administrativa

[47] Nos servimos aquí de las expresiones e ideas que Rudolf SMEND desarrolla para los derechos fundamentales, trasladables en este aspecto, a nuestro objeto de estudio. Vease su obra Constitución y Derecho Constitucional. (Traducida al español por José Mª Beneyto Pérez). Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. Primera Edición. 1985. Pags. 225 y ss.

dentro del ojo supervisor del Juez, abre el abanico jurisdiccional respecto de cualquier función, comportamiento o conducta administrativa. Nótese que no se atribuye a la jurisdicción contenciosa el control de la "actividad" o "acción" administrativa, ni mucho menos del "acto administrativo", sino de la "función", que no por casualidad, resulta omnicomprensiva no sólo de todas ellas, sino también de todo el ámbito de la inactividad.

Por otra parte, el párrafo final de la norma constitucional de comentario deja clara la arista **subjetiva** del contencioso administrativo costarricense, pues manda como listón mínimo (atención a ello): la protección tanto de los derechos subjetivos como de los intereses legítimos. Allí donde haya lesión actual o potencial de los intereses subjetivos de la persona, puede y debe estar presente el control del Tribunal competente en esta materia

Así las cosas, a modo de resumen podemos decir que, con el artículo 49 constitucional, se incorporan factores fundamentales a la jurisdicción contencioso-administrativa, a saber:

a.-) no sólo se consagra la jurisdicción a nivel constitucional como atributo del Poder Judicial, sino que se le confiere, también a nivel constitucional, un núcleo y reserva competencial específico y exclusivo: la garantía "de la legalidad de la función administrativa".

b.-) Establece un nuevo modelo de justicia contencioso-administrativa, que sin abandonar su base objetiva ("la legalidad de la función administrativa"), apunta a criterios eminentemente subjetivistas, en tanto pregona, como listón mínimo, la protección de los derechos subjetivos y los intereses legítimos. Con ello, construye **un modelo mixto o preeminentemente subjetivo.**

c-) Establece un control universal de toda conducta de la Administración Pública, cualquiera sea. Ya se trate de actos concretos, actos (disposiciones) generales, actuaciones materiales y omisiones administrativas. Toda conducta administrativa, por el hecho de serlo, está sujeta al control del Juez de lo Contencioso.

d-) Incluye a toda la Administración Pública, cualquier o ente público está cubierto por el alo de lo contencioso.

e-) Permite la protección de cualquier derecho (no solo administrativo) lesionado a cualquier persona (sea pública o privada, física o jurídica, nacional o extranjera). Pero además ordena la protección del interés legítimo, así, simplemente legítimo, sin agregados ni

condicionamientos adicionales. Todos los intereses legítimos. Con ello otorga a esta última situación de poder mencionada, un carácter sustantivo o material, de impresionantes repercusiones procesales (en la pretensión, por ejemplo) y de fondo (v.gr. la posible indemnización cuando sea lesionado por conducta antijurídica).

f-) Incorpora la garantía y protección frente a cualquier función administrativa, sin cortapisas. Dando cobertura al control de las potestades regladas y de las discrecionales. Obsérvese que aquella frase de "uso de facultades regladas", que establecía el 49 original, fue conscientemente suprimida.

Esquematizando gráficamente la postura que amparamos sobre el sistema global del contencioso administrativo, que no es más que el establecido por la Constitución, podríamos realizarlo de la siguiente manera:

1-) **Sistema Subjetivo**

individuo

(relación jurídica subjetiva individual)

derechos e intereses

legitimación rígida

2-) **Sistema Objetivo**

legalidad-ordenamiento jurídico

(deberes jurídicos-legalidad positiva)

interés general

supresión de la legitimación

3-) **Sistema Mixto o Preeminentemente Subjetivo**.

protección del individuo y de la legalidad

protección de los derechos e intereses

(individuales y colectivos)

legitimación amplia y flexible.

Bibliografía

1. **Albacar López, José Luis**. "Contenido y Alcance del Derecho a la Tutela Jurisdiccional." En *El Poder Judicial*, vol. I, 418-419. Madrid: Dirección General de lo Contencioso del Estado, Instituto de Estudios Fiscales, 1983.

2. **Alonso García (Enrique)**: "*El Artículo 24.1 de la Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Problemas Generales y Acceso a los Tribunales"*, en la obra conjunta Estudios Sobre la Constitución Política. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría. Tomo II. Madrid. España. Civitas. 1991.

3. **Aragón Reyes (Manuel)**: "*El Control como Elemento Inseparable del Concepto de Constitución".* En Política y Sociedad. Estudios en Homenaje a Francisco Murillo Ferrol. Vol. I. Centro de Investigaciones Sociológicas. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. Primera Edición. 1987.

4. **Barnés Vázquez, Javier.** "La Tutela Judicial Efectiva en la Grundgesetz (Art. 19.IV)." En *La Justicia Administrativa en el Derecho Comparado*, 144. Madrid: Editorial Civitas en relación con la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 1993.

5. **Bognetti, Giovanni.** *La Divisione Dei Poteri: Saggio Di Diritto Comparato*. Milán: Giuffrè Editore, 1994.

6. **Brewer Carías**: "*La Universalidad del Control Contencioso Administrativo"*, en la Revista de Derecho Público. Nº 46. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. Venezuela. Abril-Junio.1991.

7. **Cappelletti (Mauro)** : "*¿Renegar de Montesquieu? La Expansión y la Legitimidad de la "Justicia Constitucional"*, en Revista Española de Derecho Constitucional (REDC). Nº 17. Centro de Estudios Constitucionales. Año 6. Mayo-Agosto. 1986.

8. **Carretero Pérez, Adolfo.** "La Versión Constitucional de la División de Poderes y Funciones del Estado." *Actualidad Administrativa*, no. 5 (30 noviembre-5 diciembre 1985.

9. **De Agapito Serrano**: "*Libertad y División de Poderes. (El "Contenido Esencial" del Principio de la División de Poderes a partir del pensamiento de Montesquieu)".* Editorial Tecnos. Madrid. España. Primera Edición. 1989.

10. **Delgado Barrio (Javier)**: "*El Principio de Efectividad de la Tutela Judicial en la Jurisprudencia Contencioso Administrativa, en La Protección Jurídica del Ciudadano".* Estudios en Homenaje al Profesor Jesús González Pérez. Tomo II. Editorial Civitas S.A. Madrid. España. Primera Edición.1993.

11. **Duguit (León)**:" *La Separación de Poderes y la Asamblea Nacional de 1789. Publicación realizada en Francés en el año de 1893".* Traducida por Pablo Pérez Tremps. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1996.

12. **Embid Irujo, Antonio.** "La Relación entre los Poderes del Estado en la Reciente Dogmática Alemana." *Revista de Administración Pública*, no. 115 (enero-abril 1988).

13. **Escribano Collado**: " *Voz Deber"*, en la Enciclopedia Jurídica Básica. Tomo II. Editorial Civitas. Madrid. España. Primera Edición. 1995.

14. **García de Enterría, Eduardo, y Tomás Ramón Fernández Rodríguez**. *Curso de Derecho Administrativo*. Vol. I. 7ª ed. Madrid: Editorial Civitas, 1995.

15. **García de Enterría, Eduardo.** "Los Ciudadanos y la Administración: Nuevas Tendencias en Derecho Español." En *Hacia Una Nueva Justicia Administrativa*, 2ª ed., 63 y ss. Madrid: Editorial Civitas, 1992.

16. **García Macho (Ricardo)**: "*Problemática de la División de Poderes en la Actualidad"*, en Revista de Estudios Políticos. Nº 53. Nueva Época. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. Setiembre-Octubre. 1986.

17. **García Pelayo, Manuel.** "El 'Status' del Tribunal Constitucional." *Revista Española de Derecho Constitucional* 1, no. 1 (enero-abril 1981).

18. **Gascón y Marín, José.** "Aplicación del Principio de la Separación de Poderes en el Derecho Constitucional Moderno." En *El Principio de Separación de Poderes*, 73. Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1951.

19. **Gómez-Ferrer Morant**: *"Derecho a la Tutela Judicial y Posición Jurídica Peculiar de los Poderes Públicos"*, en Revista Española de Derecho Administrativo. Nº 33. Abril-Junio. Madrid. Civitas. 1982.

20. **González Pérez (Jesús)**: "*El Derecho a la Tutela Jurisdiccional"*. Editorial Civitas. Madrid. España. Segunda Edición. 1989.

21. **Mateu-Ros (Rafael)**: "*El Derecho Constitucional a la Tutela Judicial Efectiva y el Requisito de la Legitimación*", en Revista de Administración Pública. Nº 98. Mayo-Agosto. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España.1982.

22. **Movilla Álvarez, Claudio.** "Sistema Político y Jurisdicción Contencioso Administrativa." En *División de Poderes e Interpretación (Hacia una Teoría de la Praxis Constitucional)*, editado por Antonio López Pina, 103. Madrid: Editorial Tecnos, 1987.

23. **Peces Barba, Gregorio**. *Derechos Fundamentales*. 3ª ed. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 1980.

24. **Quiroga Lavié (Humberto)**: "*Sobre la Teoría de la Representación Popular y la División de los Poderes de Gobierno".* En Libro en Homenaje a Manuel García Pelayo. Tomo I. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 1980.

25. **Rodríguez Oliver (José María)**: "*El Artículo 24.1º de la Constitución y la Ampliación de la Competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa".* En el libro conjunto titulado El Poder Judicial. Vol. III. Dirección General de lo Contencioso del Estado. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. España. Primera Edición. 1983.

26. **Ruiz Del Castillo**: "*La Doctrina de Montesquieu. Valor Actual, en El Principio de Separación de Poderes".* Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid. España. Primera edición.1951.

27. **Sánchez Agesta, Luis.** "División de Poderes y Poder de Autoridad del Derecho." *Revista Española de Derecho Constitucional*, no. 25 (enero-abril 1989).

28. **Sánchez Morón (Miguel):** " *El Control de las Administraciones Públicas y sus Problemas".* Editado por el Instituto de España. Espasa. Calpe. Madrid. España. Primera Edición. 1991.

29. **Santamaría Pastor, Juan Alfonso**. *Fundamentos de Derecho Administrativo*. Vol. I. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1991.

30. **Schneider, Hans-Peter.** "Jurisdicción Constitucional y Separación de Poderes." *Revista Española de Derecho Constitucional* 2, no. 5 (mayo-agosto 1992).

31. **Smend, Rudolf.** *Constitución y Derecho Constitucional*. Traducido por José Mª Beneyto Pérez. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985.

32. **Suñé Llinás, Emilio**. "Sobre el Concepto de Potestad." En *Libro en Homenaje al Profesor José Villar Palasí*, coordinado por Rafael Gómez-Ferrer Morant, 1368.Madrid: Editorial Civitas, 1989.

33. **Torres Boursault (Leopoldo) "***La División de Poderes en la España de Hoy, en Sistema",* Revista de Ciencias Sociales. Nº. 117 Madrid. España